

1501903-11.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Os policiais ouvidos relataram que estavam em patrulhamento de moto quando foram alertados por terceiro sobre a ocorrência de tráfico, vindo a abordar o réu no local indicado pelo informante, logrando êxito em localizar as drogas em poder do réu.

De início, convém destacar que os depoimentos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501903-11.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501903-11.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 17h30min, próximo ao numeral 203 da Rua José Claudio dos Santos Filho, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e comarca, o acusado trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 11 porções de maconha, com peso bruto de 30,29 (trinta gramas e vinte e nove decigramas); e 16 porções de cocaína em pó, com peso bruto de 15,25g (quinze gramas e vinte cinco decigramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Segundo a exordial acusatória, o acusado dirigiu-se ao local dos fatos, em posse de drogas fracionadas em porções individualizadas e prontas para a comercialização, acima descritas, e lá passou a comercializar drogas no local, angariando, no dia dos fatos, R\$ 90,00 (noventa reais).

No mesmo dia, por volta das 17h30min, policiais militares realizavam patrulhamento próximo ao local dos fatos, oportunidade em foram abordados por um ciclista, que não quis se identificar, que relatou que numa viela, próximo da Rua Quarenta e Oito, havia avistado terceiro comercializando drogas.

Em razão disto, os policiais deslocaram-se ao local indicado, oportunidade em que

avistaram o acusado, sentado na viela, em atitude suspeita, e decidiram efetuar sua abordagem.

Constatou-se, então, que o acusado portava uma pochete, a qual continha 08 (oito) envelopes com cocaína em pó, e que junto ao acusado havia uma sacola plástica contendo mais 08 (oito) envelopes de cocaína em pó, 07 (sete) microtubos contendo maconha e 04 (quatro) tubos contendo maconha, bem como a quantia de R\$90,00 (noventa reais), em notas trocadas, produto das vendas anteriormente realizadas (fls. 52/56).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 05/07). Auto de exibição e apreensão (fls. 08). Laudo químico-toxicológico (fls. 10/15 e 137/139). Folha de antecedentes (fls. 37/38 e 164/169).

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 42/44).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 89/96).

Foi recebida a denúncia em 12 de janeiro de 2022 (fls. 103/104).

Foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva e reanalisada a manutenção da prisão (fls. 86/87, 103/104 e 146/147).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 153 e 169/172).

Em alegações finais orais o Ministério Público postulou a procedência da pretensão punitiva com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria pleiteou a exasperação da pena-base por conta da variedade das drogas. Na segunda fase presentes duas atenuantes a favor do réu. Na terceira fase pleiteou a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, por se dedicar o réu à atividade criminosa, sendo incompatível sua ação com a traficância eventual e particular. Pugnou pela aplicação do regime semiaberto e pela não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em alegações finais orais, a defesa, por seu turno, aduziu que há dúvida no tocante a autoria, sendo o acusado apenas usuário de drogas, pugnando pela absolvição ou desclassificação para o crime de uso. Em caso de condenação requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, aplicação das atenuantes da confissão e menoridade. Solicitou a aplicação da detração e imposição do regime de cumprimento de pena menos severo.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A presente ação penal comporta procedência.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo toxicológico e prova oral produzida.

A autoria segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Marcos, policial militar, relatou que na data estavam em patrulhamento de motocicleta pelo Parque Rodrigo Barreto, quando um ciclista os abordou e informou que na Rua Quarenta e Oito possivelmente havia um tráfico de entorpecente na viela. Aduziu que foram até o local, visualizaram somente um indivíduo sentado na viela, efetuaram a abordagem, em revista pessoal foram encontrados alguns entorpecentes com ele. Falou que quando ele se levantou havia uma sacola atrás dele com mais entorpecentes. Contou que quando o indagaram sobre os entorpecentes ele narrou que era para uso, não convenceu a equipe, havia dinheiro trocado com ele, então deram voz de prisão e o conduziram até a Delegacia de Polícia onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Disse que o ciclista apenas mencionou que um indivíduo estava na viela sentado, uma parte da droga estava na sacola plástica ao lado dele. Mencionou que no momento da abordagem o réu disse que era viciado em entorpecente.

A testemunha Anderson, policial militar, relatou que foi uma ocorrência simples, estavam em patrulhamento pelo bairro quando passou um ciclista que informou que na rua indicada tinha um rapaz efetuando o tráfico. Falou que foram fazer a abordagem,

viram o réu no início da viela na Rua Quarenta e Oito. Externou que seu parceiro o abordou, logo de início foi encontrado entorpecentes e uma quantidade em dinheiro. Comentou que tinha uma sacola bem próxima a ele na escada. Disse não recordar do réu.

O réu Mikael disse que tem 21 anos, trabalha como vendedor autônomo e tatuador, é amasiado e não tem filhos, estudou até o primeiro ano do ensino médio, já foi processado antes quando era menor. Declarou que no dia do ocorrido estava devendo para um rapaz que o estava ameaçando de morte. Explanou que devia ao rapaz um celular, ele era um traficante e falou que se o depoente levasse a droga ia quitar a dívida que tinha com ele. Externou que levou e estava sentado na viela, esperando o rapaz descer, quando ele estava vindo os policiais vieram e o abordaram, o menino saiu correndo. Falou que quando deu a droga na mão do rapaz ele guardou a droga, os policiais abordaram o depoente, enquanto o rapaz guardou a droga num buraco na parede e correu, não tinha nada perto do depoente. Contou que consigo tinha apenas uma porção de cocaína, o restante da droga estava guardado no muro. Contou que a droga que tinha para usar comprou com os dez reais que tinha no bolso. Informou que devia ao traficante R\$ 350,00. Externou que os R\$ 90,00 encontrados o traficante deu para o depoente entregar ao rapaz. Noticiou que era o Claudinho Taxista o apelido do rapaz, que ameaçou o depoente. Pontuou que devia ao rapaz por causa de um celular, um dia se meteram numa briga e o depoente quebrou o celular dele. Disse achar que ele iria matá-lo. Salientou que foi levar a droga, mas não estava vendendo. Disse estar arrependido.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Os policiais ouvidos relataram que estavam em patrulhamento de moto quando foram alertados por terceiro sobre a ocorrência de tráfico, vindo a abordar o réu no local indicado pelo informante, logrando êxito em localizar as drogas em poder do réu.

De início, convém destacar que os depoimentos policiais acostados mostraram-se uníssonos e coesos, revelando que o réu estava de fato na viela, quando foi abordado, não tendo o réu negado tal circunstância.

As versões do réu e da acusação, na maioria dos pontos, acabam se encontrando.

Assim, em relação ao transporte da droga pelo réu não subsistem dúvidas.

O exame toxicológico de fls. 10/15 e 137/139 confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas com o acusado.

Cabe salientar que o réu afirmou que sabia estar transportando drogas, justificando que o fez por estar sendo ameaçado por um traficante a quem devia dinheiro.

Ressalte-se que a alegação do réu de que teria sido coagido a praticar o tráfico por conta de dívida que contraiu em nada lhe socorre, visto que não se vislumbra a prática da alegada coação, sendo certo que o réu anuiu com a prática do delito.

Frise-se que não há sinal evidente de coação, seja física ou moral irresistível, tendo sido indicado apenas o apelido da pessoa que supostamente constrangeria o réu, sem maiores detalhes, não sendo possível depreender de seu relato o manifesto intuito de constrangê-lo a efetuar a entrega. Assim, não há como aplicar ao acusado o disposto no art. 22 do Código Penal.

O flagrante é inquestionável e as palavras coerentes e incriminatórias dos policiais são suficientes, haja vista que estão em conformidade com as demais provas dos autos, mormente ante a versão confessional parcial apresentada pelo réu.

Ressalte-se, neste ponto, que o réu admitiu que estava na viela e que transportava as drogas para entregá-las a terceiro. Contudo, a parte final de sua versão, no sentido de que haveria outro indivíduo no local, que correu ao avistar os policiais, deixando as drogas num muro, não merece credibilidade.

Isto porque, tais fatos não foram relatados pelos policiais e é deveras improvável que ao avistarem outro indivíduo correndo os policiais, que estavam de moto, não empreenderiam esforços para realizar a sua captura.

Na contramão da versão do réu, os policiais afirmaram que só havia ele na viela quando ocorreu a abordagem, ademais, sustentaram os milicianos que foi localizada parte da droga com o réu e outra parte numa sacola que estava próxima a ele e não

num muro.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é construída com base nos depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. E no caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e idôneo para o reconhecimento da culpabilidade do réu, porque ao lado dos depoimentos policiais, há a apreensão do entorpecente com o acusado, sem companhia de qualquer outra pessoa.

Neste escopo, ante o cotejo de todos os elementos probatórios dos autos, impõe-se a condenação do acusado.

Inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nesse contexto, de rigor se torna a condenação do acusado pelo delito de tráfico.

Não obstante, a despeito da demonstração da culpabilidade do acusado, algumas considerações merecem ser tecidas, e que carecem de valoração, especialmente para fins de individualização da pena.

Com efeito, conquanto as provas produzidas não autorizem, como já explanado sobejamente, um decreto absolutório em favor do acusado, de outro lado, os elementos amealhados aos autos não permitem concluir pela existência de um comportamento delitivo contumaz, reiterado.

No caso em questão, o acusado é um indivíduo com 21 anos de idade, sem antecedentes criminais (fls. 164/168), sendo encontrada em sua posse quantia ínfima de droga, consistente em 4,51g de massa líquida de maconha e 7,92g de massa líquida de cocaína.

Outrossim, é preciso destacar que com o acusado não foram encontrados quaisquer outros objetos, tais como anotações, cadernos de contabilidade, e outros que pudessem vinculá-lo, de uma forma mais estável ou permanente, ao comércio espúrio. Também não foi localizado qualquer armamento ou quantia expressiva de dinheiro em seu poder.

Com o acusado foram encontrados apenas os entorpecentes e a quantia de R\$ 90,00 em dinheiro.

E muito embora tal droga tenha provável origem em organização criminosa mais estruturada, conquanto esta não tenha sido minimamente identificada, o simples fato de o réu ter transportado a droga, não constitui, à vista das circunstâncias constantes dos autos, elemento probatório idôneo suficiente a concluir, com a segurança necessária, que o acusado seria efetivamente integrante de organização criminosa.

Com efeito, da análise dos autos, só se pode extrair que o réu agiu como transportador eventual, não sendo possível afirmar que o acusado integre organização criminosa, pois para que isto fique manifesto, é necessário que se verifique espontânea vontade de integrar a associação, além de fazer da criminalidade seu meio de vida principal, com habitualidade criminosa, não sendo este o caso de pessoas que são ocasional ou eventualmente cooptadas por tais organizações a praticarem delitos específicos. Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir ser o réu integrante de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343 ao caso em questão.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial da acusação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (...) 2. Contudo, no que se refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano. No caso concreto, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente

fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do redutor com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 65-66): Em relação à terceira fase de aplicação da pena, pleiteou o Parquet o afastamento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Sem razão o órgão acusador. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora Jean Carlos tenha sido surpreendido em flagrante após ter sido constatado pelo serviço de inteligência da Polícia Federal o transporte da droga, nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas. Não há informações nos autos no que tange às investigações anteriormente realizadas, limitando-se os agentes policiais a indicar a respeito apenas da apreensão. Ademais, a meu ver, é dever da acusação trazer para os autos, de forma inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no presente feito, qualquer anotação neste sentido. Assim, não havendo provas suficientes de que o acusado fazia do comércio ilícito seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, é possível afirmar que o caso presente se revele como uma ocorrência isolada, o que permite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

2.1. Como se nota, no que atine ao afastamento do redutor, a motivação do Superior Tribunal de Justiça está centrada na expressiva quantidade de droga, superior a 108 kg (cento e oito quilogramas) de cocaína, bem como na constatação da existência de “acordo de recebimento da importância de R\$ 2.000,00 a ser paga por terceiro” para transporte daqueles tablettes, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (eDOC 10, pp. 41-42). Não obstante o alto poder lesivo do entorpecente apreendido, não é possível fazer tal ilação sem o suporte de outros elementos fático-probatórios. Segundo a jurisprudência do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). Com efeito, a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciada, como no caso dos autos, a mera condição de transportador do paciente, bem como, a partir do que as decisões proferidas permitem observar, o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. Afirmou o TJMG que “nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas”. O paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína, conduta pela qual receberia remuneração. Contudo, à míngua de outros elementos probatórios, não há qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. A Segunda Turma do STF tem posição firme no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante. Para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (...) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.” (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei).

“PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade;

(b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida." (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). Dito isso, não visualizo qualquer fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente. 4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a minorante, devendo a pena do paciente seguir os moldes fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora com cópia do inteiro teor desta decisão. Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - HC: 181268 MG - MINAS GERAIS 0086299-90.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: DJe-035 19/02/2020). (grifos nossos)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME QUE DENOTA HABITUALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADA AINDA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 13 de novembro de 2019, com pedido de liminar, em favor de Pedro Eduardo Costa de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 2. Compulsando os fólios, depreende-se que não assiste razão à defesa, 1) seja porque entendendo que a imputação realizada pelos órgãos persecutórios da integração do paciente à organização criminosa é suficiente para comprovar o seu perigo à ordem pública, em razão da habitualidade criminosa ser inerente a esse tipo penal; 2) seja porque entendendo estar presente nos autos provas da sua periculosidade concreta; Senão vejamos. 3. A organização criminosa está relacionada à atuação da delinquência estruturada, que visa afrontar diária e habitualmente bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, o indivíduo que decide por livre e espontânea vontade integrar determinada associação, deve ser considerado como uma pessoa que faz da criminalidade seu meio de vida principal. Não estamos aqui a tratar das pessoas que ocasionalmente são cooptadas ou coagidas por essas organizações a praticarem delitos específicos – como, por exemplo, nos casos das 'mulas do tráfico' –, mas sim daquelas que decidiram fazer parte permanentemente da organização, fazendo das práticas criminosas verdadeiras profissões. 4. Ora, a habitualidade criminosa é condição de existência, portanto, condição sine qua non de uma organização criminosa, sendo a jurisprudência uníssona quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, cujos autos evidenciam a prática habitual de delitos. Precedentes do STJ. 5. Ainda que se diga que tal indivíduo não detém nenhuma função administrativa, de comando ou de gerência, ele é parte indispensável para o todo harmônico funcionar; e ainda se beneficia, mesmo que indiretamente, do produto oriundo das atividades criminosas diárias e habituais da empresa do crime. (...) 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0632586-38.2019.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do habeas corpus impetrado, mas para DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de janeiro de 2020

MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator Designado (TJ-CE - HC: 06325863820198060000 CE 0632586-38.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Grifo Nosso.

Tratando-se de acusado primário, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistem nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa. Demais disso, a quantidade de drogas, porquanto ínfima, autoriza o reconhecimento da minorante.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu MIKAEL LINNIKER FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 164/168). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias são normais, não sendo a quantidade ou variedade das drogas, no caso em tela, suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa, por ter o réu menos de 21 anos na data dos fatos, nos termos do artigo 65, inciso I do Código Penal, e a atenuante da confissão, nos termos da Súmula 545 do STJ, as quais não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase está presente, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão “as penas poderão ser reduzidas”, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dário Mariano da Lei de drogas comentada / César Dário Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a variedade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício.

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando o réu condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão cumulada com 166 dias-multa, no mínimo legal.

Regime prisional

Não obstante tratar-se de crime de tráfico de drogas, afastada deve ser a regra inserta no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, por determinar o cumprimento inicial da pena imposta por tráfico de entorpecentes, sempre no regime fechado, pois viola o princípio da individualização das penas, sendo certo que para a fixação de regime mais gravoso, necessário exigir-se sempre a devida motivação, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Nesse sentido:

PENA REGIME FECHADO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator o ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA TRÁFICO DE DROGAS SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DA LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, é inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA EXECUÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de 2 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 129714, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG25-04-2017 PUBLIC 26-04-2017) (grifos nossos)

Com efeito, seguindo a linha do que vem sendo sustentado pelos tribunais superiores (HC 163231), é, salutar observar que não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação.

Com essa convicção, resultante da interpretação da norma infraconstitucional ao influxo da Constituição da República, com base na pena aplicada e sendo o réu primário, o regime inicial será o ABERTO.

Deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que, mesmo computado o tempo da prisão provisória (20/07/2021 até a data atual), não haveria alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, a detração será realizada, no momento apropriado, pelo juízo da execução.

Alternativas penais

Atendidas as condições previstas art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal. Sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano, aplico também a pena restritiva de direito consistente

na prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos a entidades públicas ou privadas, a ser especificada pelo juízo de Execução, sem prejuízo do pagamento dos 166 dias-multa já fixados.

Assim, fica o réu condenado por infração ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) de reclusão, para início no REGIME ABERTO, que SUBSTITUO por prestação de serviço à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos como prestação pecuniária, além de 166 dias-multa cominado no tipo penal, no valor mínimo legal.

Direito de recorrer em liberdade

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena aplicada, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a serem aferidos para as medidas cautelares e a ausência de requisitos para a continuidade da segregação cautelar, razão pela qual revogo a prisão preventiva do réu.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Disposições Gerais

Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial. Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.

b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.

c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Com fundamento no art. 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, inexistente controvérsia acerca da qualidade e quantidade da droga, autorizo a incineração, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à Autoridade Policial.

P.I.C.

Aruja, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA